

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK.

A R R E S T

nr. 176.890 van 20 november 2007

in de zaak A. 184.401/XII-5154.

In zake : de NV BOUWCENTRALE MODERN,
die woonplaats kiest bij
advocaten T. Van De Voorde en F. Gijssels,
kantoor houdende te Eeklo,
Gentsesteenweg 56

tegen :

1. de CV TUINWIJK LOKEREN,
2. de VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN.

DE VOORZITTER VAN DE XIIe KAMER,

Gezien het enig verzoekschrift dat de NV Bouwcentrale Modern op 18 juli 2007 heeft ingediend om de nietigverklaring en de schorsing van de tenuitvoerlegging te vorderen van “de beslissing van ongekende datum van de eerste en/of de tweede verwerende partij waarbij haar inschrijving op de openbare aanbesteding voor het bouwen van 24 huurwoningen en 10 koopwoningen met bijhorende carports, garages en fietsenbergingen te Lokeren, Kouter-Roggemansdreef, als absoluut nietig wordt aanzien en zij daardoor wordt uitgesloten van de gunning van de opdracht”;

Gezien de nota's van de verwerende partijen;

Gezien het verslag over het beroep tot nietigverklaring opgesteld door auditeur P. Barra, op grond van artikel 93 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;

Gelet op de beschikking van 4 oktober 2007, waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 23 oktober 2007;

Gelet op de kennisgeving van het verslag aan partijen;

Gehoord het verslag van kamervoorzitter D. Verbiest;

Gehoord de opmerkingen van advocaat F. Gijssels, die verschijnt voor de verzoekende partij, van advocaat A.-M. Laureys, die loco advocaat G. De Smedt verschijnt voor de eerste verwerende partij, en van advocaat K. Defrancq, die verschijnt voor de tweede verwerende partij;

Gehoord het eensluidend advies van auditeur P. Barra;

Gelet op de artikelen 17 en 18 en titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

OVERWEEGT WAT VOLGT :

De gegevens van de zaak

1. De eerste verwerende partij, de CV Tuinwijk Lokeren, is de aanbestedende overheid van de in het geding zijnde opdracht, strekkende tot het bouwen van 24 sociale huurwoningen, 10 koopwoningen en bijhorende carports, garages en fietsenbergingen.
2. Bij brief van 6 september 2006 meldt de eerste verwerende partij aan de verzoekende partij dat de tweede verwerende partij op 30 augustus 2006 heeft laten weten dat de offerte van de verzoekende partij absoluut nietig was, om reden dat het veiligheids- en gezondheidsplan bij de offerte ontbraken en deze niet na opening der offertes kunnen worden bijgebracht.

3. Op 19 september 2006 dagvaardt de verzoekende partij de eerste verwerende partij voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde om te verbieden de gunningsbeslissing “aan de weerhouden inschrijver” te betekenen “en dit tot na kennisname van het arrest van de Raad van State betreffende de al dan niet schorsing van de gunningsbeslissing onder verbeurte van een dwangsom 500.000 EUR”.

Bij beschikking van 21 februari 2007 verwerpt de voorzitter de vordering wegens het niet aantonen van de hoogdringendheid aangezien de verzoekende partij nog geen procedure had ingeleid bij de Raad van State.

Het hof van beroep te Gent verwerpt op 29 juni 2007 het beroep van de verzoekende partij.

De verwerende partijen

4. De bestreden beslissing is genomen door de eerste verwerende partij. Ze blijkt te dagtekenen op 17 juli 2007. Daarin wordt formeel enerzijds beslist dat de offerte van de verzoekende partij “absoluut nietig” is en anderzijds beslist dat de NV Damman de opdracht wordt toegewezen.

De voormelde brief van 6 september 2006 bevat geen beslissing betreffende de offerte van de verzoekende partij doch is slechts een mededeling van het standpunt van de tweede verwerende partij. Formeel wordt dit advies slechts bijgevalen in de voornoemde beslissing van 17 juli 2007. De tweede verwerende partij heeft slechts een advies gegeven dat de eerste verwerende partij blijkbaar gevolgd heeft in haar beslissing.

De vraag tot buitenzakestelling van de tweede verwerende partij, zoals geformuleerd in haar nota in de schorsingsprocedure, is gegrond.

5. Overeenkomstig artikel 14, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State mag deze enkel kennis nemen van beroepen tot nietigverklaring ingesteld tegen de akten en reglementen van de onderscheiden administratieve overheden en van de wetgevende vergaderingen of van hun organen, daarbij inbegrepen de ombudsmannen ingesteld bij deze assemblees, van het Rekenhof en van het Arbitragehof, van de Raad van State en de administratieve rechtscolleges evenals van organen van de rechterlijke macht en van de Hoge Raad voor de Justitie met betrekking tot overheidsopdrachten en leden van hun personeel.

Het Hof van Cassatie stelt in zijn arrest van 14 februari 1997 (nr. C.96.0211) dat instellingen, opgericht of erkend door de federale overheid, de overheid van de gemeenschappen en gewesten, de provincies of gemeenten, die belast zijn met een openbare dienst en niet behoren tot de rechterlijke of wetgevende macht, in beginsel administratieve overheden zijn in zoverre hun werking door de overheid wordt bepaald en gecontroleerd en zij beslissingen kunnen nemen die derden binden maar dat het toevertrouwen aan een naamloze vennootschap van een taak van algemeen belang ook al is die vennootschap opgericht door een administratieve overheid en ook al is zij onderworpen aan een verregaande controle van de overheid, deze haar privaatrechtelijk karakter niet doet verliezen, ingeval zij geen beslissingen kan nemen die derden kunnen binden.

In het arrest van 10 juni 2005 (nr. C.04.0278) heeft het Hof van Cassatie in dezelfde zin gesteld dat een vennootschap die, ook al is zij opgericht door een administratieve overheid en ook al is zij onderworpen aan de controle van de overheid, geen beslissingen kan nemen die derden kunnen binden, niet de aard heeft van een administratieve overheid en het hiervoor niet terzake doet dat haar een taak van algemeen belang wordt toevertrouwd. Het Hof besliste voorts, na onderzoek van drie bepalingen van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, die op de sociale huisvestingsmaatschappijen betrekking hebben, dat uit die bepalingen niet kan worden afgeleid dat aan die maatschappijen een

beslissingsbevoegdheid wordt verleend om beslissingen te nemen die derden binden en dat de aldaar in het geding zijnde coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gewestelijke maatschappij voor de Kleine Landeigendom Het Volk aldus geen administratieve overheid is in de zin van voormeld artikel 14 van de wetten op de Raad van State.

6. In het auditoraatsverslag is ambtshalve een exceptie opgeworpen die zich op deze laatste rechtspraak steunt om in huidig geding tot gebrek aan rechtsmacht voor de Raad van State te besluiten.

Ter terechtzitting legt de verzoekende partij, met kennis van dat verslag, zich bij die exceptie neer en draagt dan ook geen argumenten aan om ze te weerleggen.

7. Uit de subsidiaire rechtsmacht van de Raad van State - als administratief rechtscollege - en uit de voormelde rechtspraak van het Hof van Cassatie mag het vermoeden worden afgeleid dat de Raad van State niet over rechtsmacht beschikt indien de verwerende partij een private rechtspersoon is aangezien deze in principe niet over de bevoegdheid beschikt om eenzijdig bindende beslissingen te nemen. Dit is dan enkel anders indien het tegenbewijs wordt geleverd en aangetoond wordt dat dergelijke beslissingsmacht wel tot de bevoegdheid van die rechtspersoon behoort en kan worden betrokken op de bestreden beslissing. Te dezen doet geen van de partijen enige poging om zulks aan te tonen en blijkt het aldus niet dat de verwerende partij, een sociale huisvestingsmaatschappij met een taak van algemeen belang maar een private rechtspersoon, bevoegdheid heeft om beslissingen te nemen die derden binden. De exceptie wordt dus aanvaard. De eerste verwerende partij heeft bij het nemen van de bestreden beslissing niet gehandeld als administratieve overheid zoals bedoeld in artikel 14, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State. Het komt dienvolgens de Raad niet toe van het beroep tot nietigverklaring kennis te nemen.

8. Het komt aldus evenmin de Raad van State toe over de vordering tot schorsing te beslissen, nu overeenkomstig artikel 17 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State de schorsing van de tenuitvoerlegging van een akte of reglement enkel mogelijk is indien deze vatbaar zijn voor nietigverklaring, hetgeen te dezen zoals hiervoor is gebleken, niet het geval is.

**OM DIE REDENEN
BESLIST DE RAAD VAN STATE :**

Artikel 1.

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen wordt buiten de zaak gesteld.

Artikel 2.

Het beroep tot nietigverklaring en de vordering tot schorsing worden verworpen.

Artikel 3.

De kosten van het beroep tot nietigverklaring, bepaald op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting, op
twintig november 2007, door :

de H.	D. VERBIEST,	kamervoorzitter,
Mevr.	S. DOMS,	griffier.

De griffier,

De voorzitter,

S. DOMS.

D. VERBIEST.